



לפני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה
יעל ליבוביץ

תיק תביעה מס': 6/14

בענין : 1. אניסה ג'ובראן

מונדר ג'ובראן

2. איילת אנג'ל

3. בחוס ג'יהאד

4. סעיד פאוזי

5. פיטר בולוס

נוהא בולוס

6. מוריס שאער

אוולין שאער

7. גסאן חרב

8. ג'אן שאמא

ג'והיינה שאמא

ע"י ב"כ עו"ד ג'ובראן ג'ובראן ואח'
מרח' אחד העם 13, ת.ד. 44535, חיפה 3144501
טל': 04-8666670/1, פקס: 04-8623868

התובעים

נ ג ד

אהרון דב מונדרי

ע"י ב"כ עו"ד עופר בן ארי ואח'
משד' מוריה 102, חיפה 34613
טל': 04-8242401, פקס: 04-8346794

הנתבע

פ ס ק - ד י נ

1. בהליך לפני עתרו התובעים למתן צו מניעה קבוע אשר יאסור על הנתבע, בעלים של שתי דירות בבית המשותף לבנות על הגג המשותף מעל דירתו.

2. הבית המשותף נושא ההליך, הידוע כחלקה 16 בגוש 11362 ברח' עבאס 45, חיפה (להלן: "הבית/הבית המשותף"), מורכב משני מבנים: המבנה התחתון נמצא ברח' עבאס 45, חיפה, ועל פי הרישום בלשכת רישום המקרקעין הוא מכיל 7 יחידות בארבע קומות. בפועל, כל שתי דירות הממוקמות באותה קומה אוחדו יחדיו מבחינה פונקציונאלית לכדי דירה אחת, כך שבפועל קיימות בבית 4 דירות במבנה, אחת בכל קומה (להלן: "המבנה התחתון"). המבנה העליון נמצא ברח' אלמותנבי 15, חיפה, ומכיל 16 יחידות דיור בחמש קומות (להלן: "המבנה העליון").

3. הנתבע שהוא בעלים של דירה המורכבת משתי דירות רשומות, המצויות בקומה השנייה של המבנה התחתון קיבל היתר בניה בתנאים המאפשר לו לבצע שיפור מיגון בחדר קיים בדירתו ובתמורה לבנות תוספת חדר ופרגולה על גג הבית המצוי מעל דירתו. התובעים הם בעלים של דירות בשני המבנים המהווים גם יחד בית משותף אחד.

טענות התביעה-

4. הנתבע מבקש לעשות שימוש בגג הבית המהווה רכוש משותף לצורך בניית קומה חלקית לשם הרחבת דירתו.

5. בבית משותף המורכב מכמה מבנים יש לבחון את היקף ההסכמות הניתנות לבנייה מקרב כלל בעלי הדירות בכל המבנים. הנתבע בעלים של שתי יחידות ולו צמודים 15/163 חלקים ברכוש המשותף. לנתבע לא קיימות הסכמות של אף לא אחד מבעלי יחידות הבית, ומשכך הוא נעדר הסכמות בהיקף הקבוע בסעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") ואף לא בהיקף קרוב לכך.

6. הבנייה המבוקשת מוסיפה קומה למבנה התחתון וכתוצאה יוסתר הנוף הנשקף מחלק מהדירות במבנה העליון.

7. מדובר במבנה המיועד להיכלל ברשימת המבנים לשימור, הוא בעל ערך תרבותי ויש לשמר אותו כמות שהוא כיום ללא שינויים מבניים.

8. שיפור המיגון וכן הוספת בניה על הגג יחייבו בניית חיזוקים קונסטרוקטיביים בתוך דירת התובעים מס' 1, הממוקמת מתחת לדירת הנתבע, וזאת על מנת לשאת את המשקל העודף שיתווסף כתוצאה מתוספת הבניה.

9. הנתבע הרחיב בעבר דירתו באמצעות סגירת מרפסת בשטח של כ-12 מ"ר, ועל כן גם אם יוכיח כי בעלי דירות בבית ביצעו הרחבה לדירותיהם הרי שזו לא תהווה "הרחבה דומה", היות והנתבע אף הוא כבר ניצל את זכותו להרחיב דירתו בדומה לאחרים.

10. גם אם תוכח "הרחבה דומה" לגבי מקצת בעלי הדירות בבית עדיין לא יעמוד לנתבע הרוב הדרוש לו לצורך הרחבת דירתו שכן נדרשת הסכמה של למצער 18 בעלי דירות מתוך 23 בעלי דירות בבית.

11. התנגדות בעלי הדירות בבית אינה נעדרת תום לב שכן הוכח כי יהיה בבנייה כדי לפגוע במראהו של המבנה וכדי לפגוע בנוף הניבט מדירות המבנה העליון. העובדה שחלק מבעלי הדירות בבית לא התנגדו לבקשת בנייה של בעל דירה אחר אף היא אינה מדגימה היעדר תום לב בהתנגדות כאן, היות ואותה בקשת בנייה לה הסכימו יתר בעלי הדירות בבית הייתה לגליזציה למצב קיים, הוסיפה על

בניה שממילא היתה קיימת בגג ולא היה בה כדי להגדיל את החסימה הנופית שכבר הייתה קיימת מעצם קיומה של אותה היחידה.

12. אין לייחס לבעלי הדירות שלא הוזמנו ולא הגיעו לעדות שיקולי התנגדות פסולים.

טענות ההגנה-

13. אין חולק כי אפשרות המיגון של היחידה של הנתבע היא באמצעות מיגון חדר קיים בדירתו ובניית חדר על הגג חלף החדר שימוגן. הבנייה אינה מנצלת אחוזי בניה כלשהם.

14. במקור נבנה המבנה התחתון כשהוא כולל 6 דירות בשלוש קומות וחדר כביסה על הגג המשותף. בשנת 2006 או בסמוך לכך רכש מר פאדי נג'אר (להלן: "נג'אר") את חדר הכביסה המצוי על הגג המשותף, הוסיף לו בניה של כ-17 מ"ר על הגג המשותף וחסם את אפשרות העלייה לגג מחדר המדרגות, וזאת ללא קבלת היתר בניה. בעלי הדירות בבית השלימו עם מעשיו ולא מחו.

15. בשנת 2012 או בסמוך לכך הגיש הנתבע בקשתו נושא ההליך להיתר בניה. במקביל הגיש נג'אר בקשה ללגליזציה בה ביקש להכשיר את הבנייה על הגג. ויוטעם, הבניה שביצע נג'אר מצויה על אותו גג אשר מבקש הנתבע לבנות עליו. בעלי הדירות בבית הסכימו לבנייה של נג'אר והלה קיבל היתר בניה אשר תוצאתו מתן זכות שימוש ייחודי דה פקטו בכל הגג המשותף, בשים לב לעובדה שתוספת הבנייה שבנה חסמה את המעבר שהיה קיים לגג המשותף.

16. נג'אר עמד בראש המתנגדים לבניית הנתבע מהטעם שיש לו עניין בכך שהגג כולו יותר בשימוש הייחודי.

17. חובת תום הלב אינה מאפשרת לתובעים להתנגד לבקשת הבנייה של הנתבע שעה שאפשרו לנג'אר לבנות תוספת בנייה דומה, אפשרו לו בנייה המונעת כניסה אל הגג המשותף וחתמו על בקשתו ללגליזציה.

18. במבנה התחתון חוברו כל 2 דירות בקומה לדירה אחת. הפועל היוצא הוא שתובעים מס' 1 ותובעת מס' 2 בעלים של דירה אחת כל אחד, וזאת על אף העובדה שבלשכת רישום המקרקעין רשומות בבעלות כל אחד מהם 2 דירות. לצורך מניין ההסכמות לבניה יש לראות כל אחד מהם כבעלים של דירה אחת.

19. דירת תובעת מס' 2 הורחבה בשנות ה-50 בשטח של כ-11 מ"ר, ודירת תובעים מס' 1 הורחבה בשנת 1970, עת נסגרה מרפסת בשטח של 11.5 מ"ר. בנוסף, תובעים מס' 1 פתחו פתח יציאה מדירתם לחצר, הקימו בחצר מחסן וגידרו את החצר לשימושם הייחודי. יש לראות את תובעים 1 ו-2 כמי שביצעו "הרחבה דומה".

20. תנאי בהיתר הבנייה של המבנה העליון היה שהמבנים יופרדו בעת הרישום. הלכה למעשה שני המבנים נפרדים לחלוטין, לרבות בהתנהלותם ותחזוקתם היומיומית, וראויים היו להירשם כבתים משותפים נפרדים. לאור זאת יש לראותם גם לצורך ההליך כנפרדים, ובעלי הדירות במבנה העליון מושתקים מלטעון כנגד הבנייה.
21. במבנה העליון שני אגפים. האגף הצפוני צופה לעבר המבנה התחתון ואילו האגף הדרומי אינו צופה לכיוון המבנה התחתון. לאור זאת ברי כי לא נגרמת פגיעה או הפרעה כלשהי לאגף הדרומי של המבנה העליון. בשנת 1972 בוצעה סגירת מרפסת בכל 16 הדירות במבנה העליון ועל כן יש לראותם כמסכימים קונסטרוקטיבית לבנייה של הנתבע.
22. בנוסף, הבעלים של תתי חלקות 22 ו-23 הרחיבו דירותיהם בתוספות בניה של כ- 66 מ"ר על גג המבנה, כל אחד, ועל כן יש לראותם כמסכימים.
23. 8 בעלי דירות במבנה העליון הגישו בקשה להיתר בנייה לבניית מרפסות זיזיות אך זנחו בהמשך בקשתם זו. 4 בעלי דירות אחרים במבנה העליון החלו מקדמים לאחרונה בקשה להיתר בנייה לבניית ממ"ד לדירתם. בעלי דירות אלו מנועים מלהתנגד לנתבע.
24. מתוך כלל הדירות במבנה העליון תוספת הבניה המבוקשת תיצור הסתרת נוף ממשית רק ל-2 הדירות בקומת הקרקע שבאגף הצפוני במבנה העליון, והסתרת נוף חלקית לשתי הדירות בקומה הראשונה שבאגף הצפוני במבנה העליון. בעלי דירות אלו נתנו הסכמתם לבנייה שביצע נג'אר על הגג, ובכך למעשה גילו דעתם שאין מדובר בהסתרת נוף מהותית. מתן הסכמתם לנג'אר, ובה בעת התנגדותם לבנייה של הנתבע, מהווים התנהגות מפלה שאינה בתום לב.
25. מהנדס אישר את הבנייה המבוקשת ואין כל יסוד לטענה כי יהיה בה כדי לפגוע קונסטרוקטיבית במבנה או לסכנו. גם לא הוגשה כל חוות דעת התומכת בטענה לפגיעה קונסטרוקטיבית.
26. רק 8 מתוך 20 בעלי דירות בבית המשותף הגישו את התביעה, ועל כן יש לראות ביתר בעלי הדירות בבית כמי שלא התנגדו לבניה. על מנת שיהיה מקום לדון בתביעה לגופא צריכים היו התובעים להיות לפחות 41% מכלל בעלי הדירות בבית, כלומר התביעה צריכה הייתה להיות מוגשת על ידי לפחות 9 בעלי דירות בבית, ולא היא.
27. אין לקבל את התנגדות תובעים מס' 1 ו-2 לבנייה על רקע העובדה שמדובר על "בניין לשימור", הן מהטעם שהם עצמם ביצעו שינויים במבנה וגם השתלטו על שטחים משותפים, והן מהטעם שהמבנה לא הוכרז כמבנה לשימור; תובע מס' 3 לא התייצב לדיונים ואינו רשום כבעל דירה בנסח הרישום של הבית. אמנם קיים בעלים רשום בשם דומה אך לא הובאו ראיות להוכחת הזיקה בין הבעלים

הרשום לתובע זה; תובע מס' 4 לא התייצב לדיונים, דירתו מצויה באגף הדרומי במבנה העליון, ועל כן הבניה לא תשפיע על הנוף הנשקף מדירתו; תובעים מס' 5 לא אפשרו ביקור בדירתם במועד הביקור וזאת מהטעם שדירתם מצויה בקומה אשר לא תושפע מהבנייה של הנתבע; תובעים מס' 6 לא התייצבו לעדות ועובדה זו צריכה לשמש לחובתם. בנוסף, בדירתם של הנ"ל נסגרה מרפסת בשטח של 12 מ"ר; תובע מס' 7 אינו רשום כבעלים של דירה בבית המשותף אלא אך כבעל הערת אזהרה ביחידה תת חלקה מס' 9. משכך מעמדו הקנייני אינו מאפשר לו להתנגד לבניה נושא ההליך. הנתבע אינו טוען לחוסר תום לב בהתייחס לבעל דירה זה מהטעם שאכן קיימת הסתרת נוף משמעותית לגבי דירות קומת הקרקע באגף הצפוני במבנה העליון, ראו עמ' 6 לסיכומים; תובעים מס' 8 לא התייצבו לעדות במקומם הופיע מר רוני מטר אשר טען כי רכש את דירתם אך לא הביא בדל ראיה התומך בטענתו זו. בהיותו בעל הערת אזהרה בלבד אין לתת מעמד להתנגדותו. לדירה זו תיגרם הסתרת נוף חלקית בלבד וגם נסגרה בה מרפסת אשר יש לראות בה "הרחבה דומה".

28. 10 בעלי דירות במבנה העליון לרבות נג'אר מהמבנה התחתון, לא הצטרפו כתובעים להליך, לא באו להעיד ולא התייצבו לביקור במקום. בעלי דירות אלו גם לא נמנו עם העוררים בהליך התכנוני או עם העותרים בעתירה המנהלית. חריג לכך הוא מר אתידל חליס שהתייצב לעדות אך לא נמנה עם התובעים. משכך אין לראות בבעלי דירות אלו מתנגדים וככל שיש לראות בהם מתנגדים אזי התנגדותם אינה עומדת בדרישות תום הלב.

ההליכים בתיק-

29. בדיון שהתקיים לפניי ביום 31.3.14 הבהיר ב"כ הנתבע עמדת הנתבע בתיק לאמור: **"אין חולק ואנו לא מסתירים את העובדה שאין לנו הסכמות בכמות הנדרשת בחוק ואף לא קרוב לכך גם אם מונים את אלו שכבר בנו, או מבקשים לבנות. אנו טוענים לחוסר תום לב בהתנגדויות"**.

30. ביום 3.9.14 התקיים דיון הוכחות בו העידו מטעם התביעה: מר מטר רוני, גב' חרב אמאל, מר אתידל חליס, מר פיטר בולס, ארבעתם בעלים של דירות במבנה העליון, וכן הגב' איילת אנג'ל ומר מונדר גובראן, כל אחד בעלים של שתי דירות במבנה התחתון. מטעם ההגנה העיד הנתבע. הצדדים הגישו סיכומי טענות בכתב בהם טענו כמפורט לעיל.

31. ביום 5.10.14 קיימתי ביקור במקום בנוכחות הצדדים ובאי כוחם, על מנת להתרשם באופן בלתי אמצעי מהנטען. להלן הנתונים אותם מצאתי רלוונטיים להליך:

(א) החלקה נושא ההליך שוכנת בין שני רחובות: חזיתה המערבית פונה לכיוון רח' עבאס וחזיתה המזרחית פונה לכיוון רח' אלמותנבי. קיימים הפרשי גובה

משמעותיים בין חלקיה השונים של החלקה באופן שהמבנה התחתון נמוך באופן משמעותי מהמבנה העליון.

(ב) המבנה התחתון בן 4 קומות. על גג המבנה קיימת היחידה שבבעלות נג'אר המוקפת בגג המבנה. ניכר כי היחידה נבנתה לפני שנים רבות אך המראה אינו מסגיר באם נבנתה בסמוך למועד הקמת המבנה או שמא הוספה כמה שנים לאחר מכן. המבנה העליון ניצב מעל קומת עמודים והוא בן 5 קומות.

(ג) החלקה בנויה בשיפוע חד יורד לכיוון רח' עבאס באופן שגג המבנה התחתון (בו מצויה דירת הנתבע) מקביל פחות או יותר לרצפת הדירות התחתונות ביותר במבנה העליון.

(ד) ניכר כי המרווח הקיים כיום בין המבנים אינו גדול ועומד על כ-8 מטרים. ואולם, היות והמבנה התחתון כולו נמוך מהמבנה העליון הרי שעל אף המרווח הקטן לא קיימת כיום קירבה בין דירות המבנה הקדמי לדירות המבנה האחורי בהיותן בנויות במפלסים שונים.

(ה) ביקור בסלון אחת הדירות התחתונות במבנה העליון הראה כי נשקף ממנה נוף של גג המבנה התחתון ומעברו ניתן לראות את הים. בדירה הסמוכה לדירה זו לא ביקרתי אך היה ברור על פי הביקור בדירה הסמוכה כי בדירה זו כבר נחסם הנוף לים על ידי דירת נג'אר. התרשמתי כי בניית הנתבע המתוכננת על גג המבנה התחתון תסתיר את הנוף שנותר לאחר בניית נג'אר.

(ו) ביקור בסלון אחת הדירות בקומה מעל במבנה העליון הראה כי נשקף ממנה נוף פתוח לים. התרשמתי כי בניית הנתבע המתוכננת על גג המבנה התחתון תסתיר את הנוף שנותר לאחר בניית נג'אר.

(ז) התרשמתי הייתה שלדירות בקומות הגבוהות יותר במבנה העליון לא יחסם הנוף בעטייה של תוספת הבנייה במבנה התחתון.

המסגרת הנורמטיבית-

32. חוק המקרקעין דן בהרחבת דירה לצורך בניית ממ"ד בסעיף 71ב(א) וזו לשונו :

"על אף הוראות סעיף 62(א) סיפה, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסויימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה, וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה, ואולם, היה נושא ההחלטה כאמור הרחבת דירה פלונית אחת או יותר לשם בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי, רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות". (הדגשה אינה במקור)

מרחב מוגן דירתי הוגדר בסעיף 71ב בלשון זו :

”מרחב מוגן דירתי” – מרחב מוגן הממוקם בתחום הדירה והמיועד לשרת את דיירי הדירה בלבד”;

המונח 'מרחב מוגן' הוגדר באותה הוראת דין כך :

”מרחב מוגן” – מקלט כהגדרתו בסעיף 11 לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי”א-1951, במתכונת מרחב הבנוי בתוך מעטפת המבנה, המיועד להגן על החוסים בו מפני התקפה והמתוכנן בהתאם להוראות לפי החוק האמור”;

33. לנוכח הסיכונים הביטחוניים בקש המחוקק לקדם יוזמות של בנית מיגון בדירות, ולשם כך הקל בתנאים והפחית את רף ההסכמות הנדרש. תיקון 28 לחוק המקרקעין הפחית את הרוב של שלושה רבעים מבעלי הדירות אשר שני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, הדרוש לשם הרחבת בניה והעמידו על הסכמה של 60% בלבד מבעלי הדירות עת עסקינן בהרחבה שהינה לשם בנייה של מרחב מוגן. הרציונל לכך היה שסל ההקלות לבניה מעין זו הכולל: פטור מהיטל השבחה, מסלול מואץ בוועדה המקומית לתכנון ולבניה ורף הסכמות מופחת יעודד את בניית המרחבים המוגנים בבניינים בהם אין מרחבים מוגנים כנ”ל.

[ראו דברי הכנסת בקריאה השנייה והשלישית של הצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 28) מס כ/183 ”דברי הכנסת” חוברת ח’].

34. חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו חיזק אמנם את מעמד קנינו של הפרט [דבר שמצא ביטוי גם בפסה”ד בענין **רוקר נ’ סלומון**, ע”א 6339/97, פ”ד נ”ה (1) 199], מאידך, משחוקק תיקון מס' 18 לחוק המקרקעין חלה התפתחות בכיוון ההתחשבות בהיבט הקומונאלי. סעיף 71ב נועד להקנות כוח לבעלי דירות בבית משותף להפקיע חלק מהרכוש המשותף לצורך העברתו לדירה נתונה ולאפשר הרחבתה, וזכות המיעוט להתנגד צומצמה עוד, מקום בו מהות הבניה הינה הקמת מרחב מוגן דירתי, התיקון האמור ”מבטא מדיניות חקיקתית החותרת להדגשת הצרכים של כלל בעלי הדירות, תוך הפחתת זכותו של המיעוט לנהוג בשרירות בקניינו, ולסרב לביצוע שינויים המיטיבים עם הכלל”. (מיגל דויטש, קנין, הוצאת בורסי, תשנ”ז-1997, כרך א', עמ' 650).

35. עוד כפי שנאמר שם (עמ' 700) כדי להקטין את הפגיעה בקנין הפרט קובע תיקון מס' 18 מערכת של איזונים ובהם הבטחת שוויון בהזדמנות הניצול של אחוזי הבניה לצורך הרחבה, בהמשך לאותה מגמה נקבע כי בעל דירה אשר הורחבה, ייחשב כמסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת בבנין.

36. הדבר בא לידי ביטוי בסעיף 71ב לחוק המקרקעין בס”ק (ג) שבו, שם נקבע:

"בעל דירה שהורחבה ייראה כמי שהסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת באותו בנין"

37. השאלה מהי "הרחבה דומה" נידונה באריכות בע"א(חי) 22123-10-10 זינגר נ' **חדד** (פורסם ביום 14.3.11), שם קבע בית המשפט כדלהלן:

"אחד הקריטריונים שנבחן, בנסיבות בהן מבקש בעל דירה לבצע הרחבה דומה בדירתו, מבוסס על השטח הנוסף שבו מבקש בעל הדירה להרחיב דירתו. נדרשת פרופורציה מסוימת, ואם כי לא זהות, בין שטח ההרחבה המבוקש והרחבות קודמות שביצע בעל דירה אחרת בבניין. כך, לא מתקבל על הדעת שמקום שדיר הרחיב דירתו במספר מטרים ספורים, תאושר הרחבה המשתרעת על עשרות מטרים כ"הרחבה דומה".

עם זאת, משנקט המחוקק במונח "הרחבה דומה", ברור הדבר מאילו כי אין לפרש את המונח "הרחבה דומה" על בסיס קריטריון בלעדי זה של שטח שנוסף לדירה, שכן אילו לכך התכוון המחוקק, היה קובע במפורש כי יראו את בעל הדירה שהרחיב דירתו כמסכים להרחבה בשטח ו/או בשיעור דומה, וכאמור, הגדרה זו לא נקבעה בתיקון מס' 18 לחוק המקרקעין. לפיכך, הגם שלא ניתן להתעלם מקריטריון השטח שנוסף, אין זה יכול לשמש כקריטריון בלעדי.....

משראה המחוקק לקבוע בסעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין כי מי שכבר הרחיב דירתו הרחבה דומה, ייראה כמי שנתן הסכמתו להרחבה, וזאת על מנת לסכל אפשרות שבעל דירה שנהנה בעבר מהרחבת דירתו, ימנע ביצוע הרחבת דירה אחרת באותו בניין, יש לפרש את המונח "הרחבה דומה" כהרחבה מסוג דומה. בהקשר זה, ובמכלול הפרמטרים הנתונים, סבורים אנו כי יש לבחון, בין היתר, את היקף הניצול או הפגיעה ברכוש המשותף שנעשה על ידי בעלי הדירות, וככל שיש בהרחבה המבוקשת משום ניצול או פגיעה גדולה ברכוש המשותף, העולה באורח ניכר על זו שנעשתה על ידי שאר בעלי הדירות בבניין, אין מקום להכשירה. (הדגשות שלי י.ל.)

38. ברוח זו, נקבע בע"א 3235/02, **אביב דוד נ' גדולטר בכבוד רונית** (פורסם בנבו), כדלקמן:

"מקובלת עלינו הפרשנות לפיה 'הרחבה דומה' כמשמעה בסעי' 71ב(ג) לחוק המקרקעין, הינה הרחבה מסוג דומה - כך בד"כ הרחבת דירה ע"י סגירת מרפסת טומנת בחובה הסכמה קונסטרוקטיבית לסגירת מרפסות ע"י בעלי הדירות האחרים באותו בנין אף אם אין שטחן של המרפסות זהה בגדלו. דא עקא, מי שסגר מרפסת לא רואים אותו כמסכים להגדלת דירת שכנו ע"ח חדר המדרגות אף אם שטח ההרחבה הינו זהה. הרחבה דומה נועדה לאפשר ניצול שטחים שההפרעה שהם גורמים לרכוש המשותף אינה שונה באופן מהותי". (הדגשה שלי י.ל.)

39. לא בכדי נקט המחוקק בלשון "הרחבה דומה" ולא "הרחבה זהה". כל דירה ניתנת להרחבה עפ"י מיקומה במבנה, תנאי הקרקע, תנאי תכנית המתאר ונתונים

אחרים המוכתבים על ידי גורמים עליהם אין לצדדים להליך שום שליטה ו/או יכולת השפעה.

40. המורס מן האמור הינו כי לאו דווקא ההסכמה הפרסונאלית המפורשת להרחבה נחוצה, ודי בכך שהדירה הורחבה כדי שבעליה "ייראה כמי שהסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת באותו בנין".

41. כאשר הבית המשותף כולל יותר ממבנה אחד יש לקחת בחשבון לצורך קביעת הרוב הדרוש את כל בעלי הדירות בכל המבנים ולא רק את הדירות במבנה שבו מבקשים את ההרחבה וראו בעניין את א. איזנשטיין, **בתים משותפים**, בעמ' 214 וכן ראו עש"א 36004-06-12 (חי) **פלאוט נ' הוד** (פורסם בנבו).

42. באשר לאופן קבלת ההסכמה קבעה הפסיקה כי היות ועסקין בזכויות קנייניות חייבת הסכמה של בעל דירה להרחבת דירה אחרת להיות ברורה מפורשת ואינה משתמעת לשתי פנים. אין להסיק מהיעדר הסכמה או מ'שיבה על הגדר' הסכמה פוזיטיבית ואין היא יכולה להילמד משתיקה או מהעדר התנגדות, כפי שכותב המלומד דגן בספרו **קניין על פרשת דרכים**, עמ' 395-396 "המגמה העיקרית של הדין הישראלי ביחס לשימוש ברכוש המשותף היא כינונו של משטר משפטי של זכויות ברורות....מגמה זו מחייבת קביעת כללים נוקשים ביחס לסמכות לגרוע מזכות החזקה ברכוש המשותף". וראו גם ע"א 5043/96 **גלמן נ' הררי** נ"ד(3) : 389

"גישה פרשנית זו אף מתחייבת מן הפסיקה המשקפת מדיניות משפטית המגנה על בעל דירה בבית המשותף, ושלפיה ויתור על זכות הנובעת מבעלותו בדירה בבית משותף בין שהמדובר בזכות ברכוש המשותף ובין שהמדובר בהסכמה לבניה (דהיינו ויתור על אחוזי הבניה) חייב להיות מפורש". (ההדגשה שלי – י.ל.).

יוצא מכאן כי אמנם מקום שתפיסת החזקה ברכוש המשותף נועדה לשם הרחבת דירה קבע החוק הסכמה מופחתת, אך עדיין צריכה זו להיות הסכמה, ולא הימנעות מהתנגדות.

43. על רקע הסקירה דלעיל אבחן כעת את נתוני מקרה זה.

דיון

44. אקדים ואציין כי מצאתי לקבל את התביעה לאחר שהוכח לי כי לנתבע לא קיימת הסכמת בעלי דירות ברוב הדרוש עפ"י סעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין ואף לא ברוב הקרוב לכך. להלן נימוקי החלטתי:

האם ניתן להחיל את הוראת סעיף 71ב(א) סיפא גם על בניית חדר שהינו תמורה לשיפור מיגון המבוצע בחדר קיים ?

45. בהחלטת ועדת הערר המחוזית מיום 23.5.13 הגדירה הועדה את הבנייה המבוקשת כדלהלן: "המשיב 2 הינו בעל הזכויות בקומה ב' מבקש למגן חדר ולנייד הזכויות לגג בצדו המערבי".

46. תיקון מס' 28 ביקש לצמצם את הרוב הדרוש הנחוץ להרחבת דירה לשם בניית מרחב מוגן דירתי. עולה השאלה מהו אותו מרחב מוגן דירתי ועל איזה סוג בנייה יש להחיל את התיקון.

47. הלכה פסוקה היא, כי נקודת המוצא לפרשנות החקיקה הינה לשון החוק, ואין לקבל פרשנות אשר אין לה עיגון בלשון החוק. הלכה זו מבוססת על פסיקת בתי המשפט וראו, למשל, דבריו הברורים של בית המשפט בענין עע"מ 2775/01 וינטר נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה "שרונים" (פורסם באתר נבו):

"נקודת המוצא לפרשנותו של חוק הינה לשון החוק, שכן אין לקבל פרשנות אשר לא ניתן למצוא לה אחיזה בלשון החוק (ראו א' ברק פרשנות במשפט - פרשנות החקיקה (תשנ"ב, כרך ב') (להלן: ברק, פרשנות החקיקה) 97). כאשר לשון החוק מאפשרת מספר פירושים, ייבחר מבין הפירושים השונים המשתמעים מלשון החוק, הפירוש אשר מגשים את תכלית דבר החקיקה".

48. נחזור, אם כן, להוראת החוק, זו קובעת, כי סעיף 71ב(א) לחוק יחול על "הוצאה של חלקים מסוימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה".
ובהמשך-

"ואולם, היה נושא ההחלטה כאמור הרחבת דירה פלונית אחת או יותר **לשם בניית מרחב מוגן דירתי**... רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות".

49. לשון החוק מאפשרת גם פרשנות ולפיה יוצאו חלקים מהרכוש המשותף לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה הדירה, **לשם** בניית מרחב מוגן דירתי ולא דווקא על ידי בניית המרחב המוגן הדירתי עצמו. לשון החוק אינה קובעת כי ההרחבה הנוספת דווקא היא - היא צריכה להיות המרחב המוגן הדירתי. אין בידי להלום כי תכליתו של החוק היא כי ההרחבה הנבנית צריכה בעצמה להיות המרחב המוגן הדירתי שהרי תכלית החוק הייתה לעודד הקמת ממ"דים ומיגונים לשעת הדחק. המילה "לשם" מבהירה כי ההחלטה צריכה להיות כזו המאפשרת בניית מרחב מוגן. בהינתן שלשם בניית חדר משופר מיגון על הגג די היה בהסכמת 60% מבעלי הדירות בבית, אזי נכון לדעתי ליתן פרשנות לחוק ולפיה מקום בו שופר

המיגון דווקא בחדר קיים בבית ובמקומו נבנה על הגג חדר אחר, מטעמים ככל שיהיו, יהא הרוב הדרוש זהה.

50. הנתבע ביקש לבצע מיגון לדירתו על דרך של בניית חדר משופר מיגון. מאחר והוועדות לתכנון ולבניה הכירו בעובדה כי ברבים מהבתים בהם מוגשת הבקשה לבניית חדר שיפור מיגון מעדיפים בעלי הדירה מטעמים תכנוניים/ בטיחותיים וכד', לבצע שיפור מיגון לחדר קיים בבית ו"תמורתו" לבנות חדר אחר, נותנות וועדות התכנון והבניה זיכוי באחוזי הבניה תמורת החדר הקיים בו בוצע שיפור המיגון באופן שההרחבה אינה כרוכה בתוספת שטח עיקרי למבנה. שכן ממה נפשך: בין אם תתיר הועדה לתכנון ובניה בנייתו של חדר חדש שייבנה כחדר משופר מיגון, בין אם תתיר בנייתו של חדר רגיל בתמורה למיגונו של חדר קיים בבית, נמצא כי יוסף חדר נוסף לדירת הנתבע. כך או כך עסקינן בהרחבת דירה שמטרתה בניית מרחב מוגן דירתי. ברי כי עמידה דווקנית על כך שדווקא החדר החדש שייבנה הוא זה שיבוצע בו שיפור במיגון על מנת שיחשב כממ"ד עשויה להביא לשינוי בתוכניות הבניה של הנתבע, תוך הסבת החדר החדש לחדר משופר המיגון, אך ללא שוני מהותי בהיקף הבניה המתבקש.

51. אין בידי הלום כי לשון החוק התכוונה כי בחלקים שיוצאו מהרכוש המשותף דווקא ייבנה המרחב המוגן הדירתי. לעניות דעתי, בניית חדר חדש תוך הסבתו של חדר קיים למטרה זו תשיג – ללא שינוי ו/או פגיעה מהותית- את התכלית אליה כיוון המחוקק.

52. לאור האמור ניתן לטעמי להחיל את הוראת סעיף 71ב(א) סיפא גם על הבנייה שמבקש הנתבע לבנות ועל כן נדרשת לנתבע הסכמה בשיעור של 60% מבעלי הדירות בבית המשותף.

53. לאור הפסיקה שהובאה לעיל ברור כי את היקף ההסכמות שניתנו לבנייה יש לבחון מקרב שני המבנים מהם מורכב הבית המשותף. אפילו הייתה מוכחת טענת הנתבע כי היתר הבניה כלל דרישה לביטול הקשר בין המבנים, לדידי אין עוד משמעות לתנאי זה מקום בו נרשמו שני המבנים כבית משותף אחד בלשכת רישום המקרקעין, ועל כך אין חולק. הנתבע רכש דירתו בהסתמך על הרישום הנוכחי, לא פעל לתיקון הרישום לצורך רישום כל מבנה כבית משותף נפרד, ואף לא הוכיח כי קיימת היתכנות מבחינה רישומית או תכנונית לחלוקת החלקה לשתי חלקות נפרדות ולרישום כל מבנה כבית משותף נפרד.

54. משכך, ולאור הרישום הקיים יש לראות בשני המבנים כבית משותף אחד. עפ"י הפסיקה שהובאה לעיל ברי כי גם העובדה שכל בית משותף מתנהל בפועל באופן נפרד אין בה כדי להעלות או להוריד. לאור האמור על הנתבע להוכיח כי עומד לו הרוב הדרוש מקרב בעלי הדירות בשני המבנים.

55. אינני מקבלת את טענת הנתבע כי לצורך חישוב כמות ההסכמות בבית המשותף יש להכיר רק ב-20 יחידות, כפי שקיימות בפועל, ולא ב-23 יחידות, כפי שרשום בנסח הרישום. אין לקבל את עמדת הנתבע ולפיה מרגע שאוחדו שתי דירות בבית ליחידה אחת יש לראות בהן דירה אחת לצורך מניין הקולות הנדרש לשם הרחבת דירה. החוק הרלבנטי בענייננו הינו חוק המקרקעין ולא חוק התכנון והבניה ומספר היחידות כמו גם הגדרתן נגזרות ממנו.

חוק המקרקעין בסעיף 52 שבו מגדיר "דירה"-

"חדר או תא, או מערכת חדרים או תאים, שנועדו לשמש יחידה שלמה ונפרדת למגורים, לעסק או לכל צורך אחר";

בבית המשותף האמור נרשמו 23 חלקות משנה ולכן אני קובעת כי כמות ההסכמות תימנה מקרב 23 הדירות הרשומות בבית המשותף.

56. טוען הנתבע כי על התובעים להוכיח כי 41% מכלל בעלי הדירות בבית מתנגדים לבניה שלו על מנת שתוכח התביעה. 41% מ-20 דירות משמעם התנגדות של לפחות 9 דירות בבית. לטענתו, לאור העובדה שהתביעה הוגשה רק על ידי 8 תובעים ברי כי לא קיימת התנגדות בהיקף הדרוש לבקשת הבניה.

57. אין בידי לקבל טענה זו. אין להלום כי המתנגדים לבניה הם אלו שיצטרכו להוכיח שהם לפחות 41% מכלל בעלי הדירות בבית. בטענתו זו של הנתבע מבקש הוא להפוך את היוצרות. בעוד שהמחוקק קבע כי על מי שמבקש לבנות חלה החובה להמציא הסכמות בהיקף הקבוע בסעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין, לענייננו 60%, טוען הנתבע כי על המתנגדים דווקא להוכיח כי הם למעלה מ-40% מבעלי הדירות בבית.

58. מהפסיקה שהובאה לעיל עלה מפורשות כי לאו התנגדות אינה מהווה הסכמה לבניה, וכי על ההסכמה לבניה להיות ברורה ומפורשת. אין חולק כי מקרב 23 יחידות בבית קיימת הסכמה מפורשת לבניה רק של שתי היחידות שבבעלות הנתבע.

59. לשתי הסכמות אלו ביקש הנתבע לצרף הסכמות קונסטרוקטיביות של בעלי דירות נוספים בבית, כאלו שביצעו "הרחבה דומה".

האם קיימת "הרחבה דומה" של מי מבעלי הדירות בבית?

60. אבחן להלן את בעלי הדירות בבית המשותף לגביהם טען הנתבע כי ביצעו "הרחבה דומה".

תובעים מס' 1-

61. הנתבע טען כי תובעים אלו בנו בחצר מחסן אשר יש לראות בו "הרחבה דומה". עצם הבנייה לא הוכחה. הנתבע הכחיש בעדותו כי בנה מחסן וטען כי מחסן זה קיים מאז נבנה הבית, וכי לא הוכח בראיות מועד הקמתו. מכל מקום, אפילו היה מוכח כי המחסן נבנה במועד מאוחר יותר לא הייתי רואה בו "הרחבה דומה", מהטעם שכבר נקבע בפסיקה שמחסן אשר אינו המשך רציף של הדירה לא ניתן לראות בו הרחבת דירה. ראו בעניין זה רע"א 1462/10 עטייה נ' שגיא (מיום 2.8.12). משלא ניתן לראות במחסן נפרד מהדירה הרחבת דירה ממילא אין הוא יכול להוות "הרחבה דומה" לזו שמבקש הנתבע לבנות במסגרת הליך זה.

62. תובע מס' 1 אישר בעדותו כי בדירתו נסגרה מרפסת בשטח של כ-11.5 מ"ר. ראו עדותו בעמ' 16 לפרוטוקול שורה 18. אכן סגירת מרפסת מהווה הרחבה של הדירה, ראו בעניין ע"א (י-ס) 1415/00 אברהם נ' אזרד (4.7.2001), אך הנתבע העיד כי גם בדירתו נסגרה מרפסת בשטח של 12 מ"ר, ראו עדות הנתבע בעמ' 23 לפרוטוקול שורות 35-38. מחומר הראיות עלה כי הן הנתבע הן תובעים אלו הרחיבו דירתם ע"י סגירת מרפסת קיימת בשטח דומה. לאור זאת לא ניתן עוד לזקוף את סגירת המרפסת לבנייה אותה מבקש הנתבע לבצע כעת.

63. מעבר לסגירת המרפסת לא טען הנתבע, וממילא לא הוכיח, כי תובעים אלו ביצעו הרחבה נוספת כלשהי של דירתם. אמנם הנתבע טען כי תובעים אלו תחמו בגדר חלקים מהחצר המשותפת ופתחו פתח יציאה בקיר החיצוני של הבית אל הגינה, אך אינני מוצאת לנחוץ לבחון טענות אלו מהטעם שאפילו היו מוכחות הרי שלכל היותר מדובר בשינויים ברכוש המשותף אך אין בהם כדי הרחבת דירה ומשכך אין הם יכולים להוות "הרחבה דומה".

64. לאור האמור לא מצאתי כי תובעים אלו ביצעו "הרחבה דומה".

תובעת מס' 2-

65. הנתבע העיד כי בדירת תובעת זו נבנתה בהיתר בשנות ה-50 תוספת של מטבח ונוחיות בשטח של כ-11.5 מ"ר. עדותו זו לא הוכחה. יחד עם זאת, היות והנתבע העיד, כאמור לעיל, כי בדירתו נסגרה מרפסת בשטח של 12 מ"ר אזי גם לגבי תובעת זו לא ניתן עוד לזקוף את ההרחבה המבוקשת כיום כנגד ההרחבה שבוצעה בדירתה בעבר. מדובר בהוספת שטח דומה המשמשת לצרכי הרחבת הדירה.

הבעלים של יחידה תת חלקה מס' 7-

66. מעדות הנתבע, שלא הוכחה, וכן מהראיות שהוגשו עלה כי יחידה זו הייתה במקור בשטח של כ-25 מ"ר והוגדרה כחדר כביסה. במהלך השנים הוסף ליחידת נג'אר שטח של כ-16 מ"ר בבנייה קלה לשם הרחבתה. הרחבה זו נעשתה על גג הבית, ובשטח דומה להרחבה שמבקש הנתבע כעת לבנות. מוצאת אני לקבוע כי יש לראות בבנייה שבוצעה ביחידה זו בבחינת "הרחבה דומה". המחוקק קבע כי יראו מי שביצע "הרחבה דומה" כמסכים לבנייה של אחר. המחוקק לא קבע כי נדרש שההרחבה תהיה "הרחבה זהה". לפיכך, הגם שאין זהות מספרית מוחלטת בשטח ההרחבות מוצאת אני כי מדובר ב"הרחבה דומה שנועדה לאפשר ניצול שטחים שההפרעה שהם גורמים לרכוש המשותף אינה שונה באופן מהותי", ועל כן יש לראות בנג'אר כמי שביצע "הרחבה דומה". לאחר שבחנתי את שתי ההרחבות לא מצאתי לקבוע כי סגירת המרפסת שביצע הנתבע "מתקזזת" כנגד הרחבת דירת נג'אר על גג המבנה, הן מהטעם ששטח ההרחבה של נג'אר עולה על שטח המרפסת שנסגרה בדירת הנתבע, והן מהטעם שקיים דמיון רב בין הרחבת נג'אר לבין ההרחבה שמבקש הנתבע לבצע.

67. לאור האמור יש בהרחבת נג'אר כדי "הרחבה דומה".

המרפסות שהוסיפו 16 בעלי הדירות במבנה העליון-

68. הנתבע העיד בעמ' 19 לפרוטוקול שורות 31-30, ועדותו לא הוכחה, כי כל 16 הדירות במבנה העליון הרחיבו דירותיהם, עת נסגרה בכל דירה מרפסת בשטח של 12 מ"ר. לאור זאת טען הנתבע כי יש לראות בהם כמי שביצעו "הרחבה דומה". לא מצאתי לקבל טענתו זו. היות והנתבע סגר אף הוא מרפסת והרחיב דירתו באותו יחס לא ניתן עוד לזקוף הרחבה זו לבנייה אותה מבקש הנתבע לבצע כעת, והללו לא ייחשבו כמי שביצעו "הרחבה דומה" ולפיכך אין לראות בהם כמסכימים להרחבת הנתבע.

4 דירות במבנה העליון הגישו בקשה להיתר בנייה לבניית ממ"ד-

69. הנתבע העיד בעמ' 22 לפרוטוקול שורות 15-18 כי 4 דירות במבנה העליון הגישו לאחרונה בקשה להיתר בנייה לבניית ממ"ד לכל דירה, ויש לייחס להם הסכמה קונסטרוקטיבית.

70. בע"א 2821/01 (חיי) וילסקר נ' לויט, (מיום 8.8.02), עמדה לדיון השאלה האם די בכך שבעל דירה הגיש בקשה להיתר בנייה כדי לראותו כבר כמסכים להרחבה דומה של האחר, וקבע בית המשפט כי על מנת שבעל דירה יראה כמי שמסכים הסכמה קונסטרוקטיבית לבנייה של בעל דירה אחר בבית יש להוכיח כי ניתן לו

היתר בנייה וקיימות בידי הסכמות של יתר בעלי הדירות בבית. וכך נקבע בפסק הדין:

"משהגיש בעל דירה בקשה להיתר להרחיב את דירתו ולהגדיל את שטח הדירה, הביע דעתו כי הוא מבקש לפעול כך בפועל. אין דרכו של אדם להגיש בקשה להיתר, ולעבור את כל השלבים הנדרשים לצורך קבלת היתר, אם אין לו הכוונה לבצע בנייה בפועל. מה עוד, שרשאים היו וילסקר, בכל שלב של הדיון, ובטרם מתן ההיתר להודיע על חזרתם מן הבקשה שהוגשה.

בנסיבות אלה יש לאשר את הדברים שנאמרו על ידי כבוד המפקחת בסעיף 10 להחלטה:

..."הדעת לא סובלת פירוש לפיו בעל דירה ינקוט את כל הצעדים המינהליים לקידום רישוי בנייה, צעדים הכרוכים בשכירת שירותים מקצועיים ובהוצאות כספיות ומבוטלות, ובכל זאת יטען כי אין לראות בפעילות אקטיבית זו, המבטאת כלפי חוץ, משום פעילות העולה בקנה אחד עם הפגנת כוונה כנה ואמיתית להרחיב דירתו."

דברים אלה אינם רק עולים כמסקנה הגיונית וישירה מהפעולות בהן נקטו וילסקר, אלא יש לראותן גם כקביעת ממצאים עובדתיים, שיש לחזור ולאשרם גם בפנינו.

גם אם אין בכוונת מגיש הבקשה לממש ההיתר, עדיין יש לראותה כהסכמה, שהרי כוונת ההרחבה הוצאה אל הפועל, הכל בהעדר ראיות שיש בהן להצביע על כוונה חריגה אחרת.

כל מסקנה אחרת, תותיר בידי המתנגד, במקרה כזה, כפי שציננה כבוד המפקחת, אפשרות "להחזיק את בעלי הדירות האחרות כבני ערובה" (ראה סעיף 11 להחלטה)

לאור האמור, ניתן לאשר את ההחלטה שניתנה על-ידי המפקחת.

יחד עם זאת, כפי שהבהרתי, נראה לי כי ראוי לסייג את ההחלטה בנושא זה.

ניתן אכן לראות בקשה כזו להיתר כהסכמה קונסטרוקטיבית, ואולם זאת בכפוף לכך, שמבחינה תכנונית תאושר הבקשה, וכי תינתן הסכמה לבקשתו על ידי רוב בעלי הדירות. (הדגשה אינה במקור)

לכאורה אין מניעה שבעלי הדירות בבית המשותף יסכימו לבקשת ההרחבה של האחד, ויסרבו לבקשתו של האחר, הגם שבהעדר נימוקים סבירים לסירוב, יוכל הנפגע לנקוט בהליך משפטי מתאים. ואולם, במקרה כזה, ספק אם ניתן לראות את מגיש הבקשה, כ"בעל דירה שהורחבה" מאחר שזכותו לעשות כן, טרם גובשה.

לעומת זאת, אם ניתן היתר וניתנה הסכמת הרוב לתוספת הבנייה - גם אם לא ביצע ההרחבה בפועל - אין הוא יכול לסרב לבקשה דומה של בעל דירה אחר, ובמקרה כזה, ייחשב כ"בעל דירה שהרחבה".

71. בנסיבות אלו ולאור האמור לעיל לא ניתן בשלב זה, בו רק הוגשה הבקשה להיתר בניה, לראות ב-4 דירות אלו כמי שביצעו "הרחבה דומה". עם זאת, ככל שיצליחו בעלי דירות אלו לקבל היתר בניה והסכמות בעלי הדירות בבית ברוב הדרוש, או אז ניתן יהיה לראות בהם כמי שביצעו "הרחבה דומה" אף טרם שיוציאו לפועל את הבניה.

הבניה שביצעו הבעלים של יחידות תתי חלקות 22 ו-23-

72. מחומר הראיות ומעדות הנתבע, בעמ' 18 לפרוטוקול שורות 22-23 ובעמ' 19 לפרוטוקול שורה 35, אשר לא הוכחשה, עלה כי הללו הרחיבו דירותיהם בשטח של כ-60 מ"ר כל יחידה על גג המבנה העליון. לאור העקרונות אשר פורטו לעיל לעניין "הרחבה דומה", מוצאת אני לקבוע כי הבנייה שביצעו בעלי דירות אלו, אף הם על הגג לצורך הרחבת דירותיהם, ובשטח העולה בהיקפו משמעותית על הבקשה נושא ההליך, עולה כדי "הרחבה דומה" לזו שמבקש הנתבע לבנות על גג המבנה התחתון.

בקשות לבניית מרפסות זיזיות-

73. הנתבע הוסיף וטען כי 5 דירות במבנה העליון הגישו בקשות להיתר בנייה לבניית מרפסות זיזיות, אך הודה כי הללו לא יצאו לפועל וכי בקשתם בסופו של יום נדחתה. ראו עדותו בעמ' 19 לפרוטוקול שורות 38-41. משכך, בקשות לבנייה אשר לא יצאו אל הפועל ואף לא אושרו במוסדות התכנון אין בהן כדי להעלות או להוריד לעניין כמות הדירות שניתן לראות בהם כמי שביצעו "הרחבה דומה".

74. עפ"י סעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין, אשר הובא לעיל, צריך הנתבע לגייס לצורך בניית תמורת שיפור המיגון הסכמות של 60% מבעלי הדירות בבית בשני המבנים, קרי, נחוצות לו הסכמות של 14 בעלי דירות בבית.

75. מניין ההסכמות המפורשות (של הנתבע בלבד) בצירוף ההרחבות הדומות, אשר נסקרו על ידי, עומד על 5 דירות בלבד מתוך 23 בעלי הדירות בבית (הסכמות הנתבע שהוא בעלים של תתי חלקות 5 ו-6, הסכמות קונסטרוקטיביות של בעלי יחידות 7, 22 ו-23). ככל שיתקבל היתר לבניית הממ"דים כמפורט לעיל, ובהנחה שתינתן לאותם בעלי דירות גם הסכמה קניינית כדין, או אז תעמוד לנתבע הסכמה קונסטרוקטיבית גם של 4 יחידות אלו. אפילו אצא מנקודת הנחה שיש לראות את מגישי הבקשה להיתר בנייה לבניית ממ"ד עם המסכימים, עדיין

יעמדו לנתבע הסכמות של 9 מתוך 23 בעלי דירות בבית המשותף בלבד, ובכך לא די.

סוגיית תום הלב-

76. הלכה היא, כי גם כשאין רוב מספיק, יהיו מקרים בהם יאשר בית המשפט בניית ממ"ד או הרחבה, כיוון שמצא כי ההתנגדות היא בחוסר תום לב. ראו דיון נרחב בסוגיה ברע"א 6339/97 **רוקר נ' סלומון** פד נה(1) 199, וראו בע"א (חי) 835/08 **צבי נגד פרי**, (מיום 18.11.09) את פסק דינו של הרוב מפי כב' השופטת וסרקרוג וכב' השופט דר' עדי זרנקין; וראו מנגד את עש"א (חי) 13877-04-09 **קיסרי נ' שלומוב** מיום 16.8.10 שם מצא בית המשפט לסייג את האפשרות להתערב בשיקולי ההתנגדות של בעל דירה רק למקרים חריגים, וכן ראו את עש"א 17181-05-11 **אברהם נ' פדאל** מיום 20.9.11 (להלן: "פס"ד פדאל") שהינו פסק דין בערעור על פסק דינה של כב' המפקחת וינברגר (כתוארה דאז) אשר מצאה להתיר בניה גם בהיעדר הרוב הדרוש לאחר שמצאה כי התנגדות בעלי הדירות הייתה נעדרת תום לב. ערכאת הערעור מצאה לקבל את הערעור שהוגש על פסק הדין ואלו נימוקיה מפי כב' השופטת וסרקרוג:

"שם (-בע"א 835/08 נטלה נ' פרי, הוספה שלי י.ל.) בדעת רוב נקבע כי אין בהגבלה שנקבעה בסעי' 71 לחוק המקרקעין כדי לאפשר למי מן המתנגדים לבוא לבית המשפט ולהתנגד מבלי להעלות את נימוקי להתנגדותו (דעה חולקת, כבוד השופט כהן).

במקרה דנן, גם על פי הדעה של הסמכות לבחון את נימוקי המתנגדים, סבור ההרכב שטענה כבוד המפקחת משסברה במסגרת סמכותה לבחון את הנימוקים כי יש לראות את אלה, כטעמים שהועלו שלא בתום לב וכי סמכותה של הרשות השופטת לבוא לשקול את השיקולים על ידה, במקום הדיירים האחרים. סמכות כזו אינה קיימת. בנסיבות העניין, אין לייחס העדר תום לב למערערים, והיה מקום לאשר התנגדותם למנוע הבניה.

לעניין הטענה כי תיווצר מעין זכות וטו לדיירים בבניין הקדמי בנוגע לכל בנייה שיתבקשו הדיירים לבצע בבניין האחורי, יש להשיב, כי על רוכשי הדירות במבנה האחורי היה לקחת נתון זה בחשבון בעת הרכישה, ובכל מקרה, בדעת רוב (השופטים ש' וסרקרוג והשופט ר' שפירא) אם אכן תהיה התנגדות סתמית או נוגדת עקרונות שיטת המשפט, הסמכות של ביהמ"ש לבדוק את ההתנגדות עומדת בעינה אך אינה יכולה לבוא במקום הדיירים אלא על דרך בחינה נדרשת.

ובהמשך-

"בשאלה הראשונה שהיא עקרונית, אם לאור האמור בסעיף 71 לחוק המקרקעין שכותרתו "שינויים ברכוש המשותף ובזכויות הבנייה" עומדת הזכות למתנגד שלא לפרט את נימוקיו להתנגדות, אפילו אלה

סתמיים ואפילו נוגדים הם את עקרונות שיטת המשפט ותום הלב-
שהוא אחד מעקרונות היסוד בשיטה-סבורה הייתי וסבורה אני שאין
לאפשר התנגדות ללא הנמקה. בשלב השני שלאחר הבאת הנימוקים
סמכותו של ביהמ"ד לבוא ולבחון נימוקים אלה היא מצומצמת ביותר.
אכן, אין לדעתי לאפשר התנגדות סתמית שאינה עניינית או שיש בה
משום שימוש לרעה בזכות הקניין, כך נאמרו על ידי בפס"ד צבי
והוספתי כדוגמא כאשר בעלים של מספר דירות בבניין מתנגדים מתוך
כוונת קנטור או בשל "מוצא או נסיבות אחרות הנוגדות את עקרונות
שיטת המשפט ואשר אין בהם דבר או חצי דבר עם הפגיעה הקניינית
 לכשעצמה..." (הדגשה שלי י.ל.)

77. סיכום הפסיקה בנושא מעלה כי ככלל נתונה למפקח על רישום מקרקעין הסמכות לבחון את נימוקי ההתנגדות, וכי התנגדות שאין נימוקים בצידה לא תתקבל. יחד עם זאת, דעתם של כל השופטים שישבו בדין הייתה כי יש לצמצם סמכות זו ביותר, קרי, למפקח על רישום מקרקעין לא קיימת הסמכות לשקול חלף בעלי הדירות את השיקולים ולבטלם מקום בו דעתו שונה מדעתם.

ולענייננו-

78. הנתבע ביקש שאקבע כי התנגדותם של יתר בעלי הדירות בבית או העובדה שלא ניאותו לתת הסכמתם לבנייה שלו עולה כדי חוסר תום לב. טעמיו לכך היו כדלהלן: בעלי הדירות נתנו הסכמתם ללגליזציה של ג'יאר אשר בנה בנייה דומה לזו שמבקש הנתבע לבנות על הגג; למעט תתי חלקות 8 ו-9 אשר יפגעו כתוצאה מהבניה, הבניה המבוקשת לא תגרום נזק כלשהו לאף דירה אחרת בבית ועל כן התנגדות היתר נעדרת תום לב; תובעים 1 ו-2 עשו שינויים ברכוש המשותף ללא שקיבלו לכך הסכמות ועל כן הם מנועים מלהתנגד לבקשתו.

79. לאור הפסיקה שהובאה חובה על בעלי דירות המתנגדים לבנייה לפרט את נימוקי התנגדותם, ודינם של בעלי דירות שלא פירטו את נימוקי התנגדותם שהתנגדותם לא תתקבל. לטעמי, את דבריי כב' השופט וסרקרוג בפס"ד פדאל, לפיהם היא סבורה שאין לאפשר התנגדות ללא הנמקה, יש ליישם מקום שבעלי דירות לא חתמו על הבקשה להיתר בנייה של הנתבע, וגם לא טרחו להביא את נימוקי התנגדותם לא על דרך של הגשת תביעה, לא על דרך של התייצבות לעדות ולא בכל דרך אחרת. להבדיל מכך, בעלי הדירות שהגישו את התביעה נימקו בכתב התביעה את נימוקי התנגדותם, ואינני מוצאת כי ראוי לקבוע כי תביעה שהוגשה ע"י 8 בעלי דירות הכרח הוא שכל ה-8 יעידו שאם לא כן התנגדותם תחשב חסרת תום לב וכתוצאה מכך בטלה.

80. התביעה הוגשה על ידי 8 תובעים אשר הם בעלים של 10 יחידות בבית המשותף (תובעים מס' 1 ותובעת מס' 2 הם בעלים של שתי דירות כל אחד). הללו פירטו בכתב התביעה את נימוקי התנגדותם. בנוסף התייצבו לעדות 2 בעלי דירות

נוספים אשר אינם נמנים על התובעים: עד תביעה מס' 1 ועד תביעה מס' 3. הללו פירטו בעדותם את נימוקי התנגדותם.

81. נמצא עם כן כי בעליהם של 12 דירות בבית המשותף הביאו לפניי את נימוקי התנגדותם, הללו ייבחנו לאורם של העקרונות אשר התוותה הפסיקה בנושא תום הלב.

82. עד תביעה מס' 1, מר מטר רוני, טרם נרשם כבעלים של יחידה בבית, אך הנ"ל העיד כי רכש את הדירה, תת חלקה מס' 12, מבעליה הרשומים, ה"ה שאמא, ומחזיק בה כבר שנה, נתון זה לא הוכחש. ה"ה שאמא לא נתנו הסכמתם לבניה של הנתבע, בשל העובדה שכבר מכרו דירתם לה"ה מטר. במקרה בו בעל דירה מכר דירתו אכן מתבקש הוא שאותו בעל דירה יחדל מלקבוע את עתידו של אותו בית משותף, אפילו נותר הוא רשום כבעליה של הדירה, וכי ממועד שעברה החזקה לרוכשים (ויתכן שאף ממועד מוקדם יותר) יקבעו הם את עתידו של הבית. מר מטר שראה עצמו כבעלים של הדירה, על אף שטרם נרשם ככזה, הגיע והעיד כי הוא מתנגד לבניה מהטעם שזו תפגע בו. על התנגדות ה"ה שאמא ליתן הסכמה לבנייה לא ניתן לטעון כי היא נעדרת תום לב, היות וכאמור מרגע שמכרו את הדירה ברי כי אין להם עוד עניין בבית ובנעשה בו. ממועד המכירה סביר כי עניין בנעשה בבית קיים דווקא לרוכשים והללו אכן טרחו והתייצבו להעיד.

83. לא מצאתי חוסר תום לב בעובדה שאותם בעלי הדירות בבית שנתנו הסכמתם לבנייה של נג'אר, מתנגדים לבנייה של הנתבע. בעדויות כל עדי התביעה עברה כחוט השני הטענה כי הבנייה שביצע נג'אר הייתה עובדה קיימת טרם שרכשו את דירתם, ומשכך הם נטו להסכים לבקשת הלגליזציה שהגיש נג'אר לאותו מצב קיים. ברי כי בעלי דירות נוטים להשלים עם מצב קיים, אפילו הוא גורם להם נזק, אך יבקשו למנוע פגיעה דומה שטרם באה לעולם.

84. לעניין השינויים שביצעו תובעים 1 ו-2 ברכוש המשותף, לא מצאתי הכיצד שנויים שביצעו התובעים 1 ו-2 ברכוש המשותף, ככל שביצעו, או תפיסת חזקה ברכוש המשותף, ככל שנעשתה, מונעים מתובעים אלו להתנגד לבקשת הבנייה של הנתבע. הנתבע רשאי לפעול בעניין זה ככל שהוא מוצא לנכון, ברם, לא מצאתי לקבוע כי התנגדות תובעים 1 ו-2 היא חסרת תום לב.

85. הנתבע טען כי התנגדות תובעת מס' 2 לכך שייעשו שינויים כלשהם במבנה מטעמים של שימור המבנה שהוא מבנה היסטורי, נעדרת תום לב, היות והבית לא הוכרז כמבנה לשימור, והיות וכבר נעשו בו שינויים מבניים בעבר.

86. בביקור שערכתי במקום התרשמתי כי לא יהיה בבניה האמורה כדי לפגוע במראהו של הבית או של המתחם אלא דווקא לשפרו. בביקור מצאתי כי על חצי הגג כבר נבנתה תוספת הבניה של נג'אר והבנייה נושא ההליך תביא לרצף בנייה על הגג אשר דווקא ישפר את מראה הבית. על אף העובדה שזו התרשמותי אין

להלום שהעדפותיה האישיות של תובעת מס' 2, המעדיפה הותרת המצב החיצוני על כנו, יפורשו כחסרות תום לב.

87. זאת ועוד, מחומר הראיות ואף מעדות הנתבע בעצמו עלה באופן ברור כי בבנייה נושא ההליך יהיה כדי לצמצם את הנוף, האוויר והאור המגיעים לדירות תתי חלקות מס' 8 ו-9 (וראו עדות הנתבע בעמ' 22 לפרוטוקול שורות 23-31 ובעמ' 23 שורה 7). במצב דברים זה לגיטימי בעיניי שבעלי דירות בבית ימצאו להעדיף את המצב הקיים, מתוך גילויי הזדהות עם אותם בעלי דירות אשר יפגעו מהבניה, על פני מתן הסכמה לנתבע לבנות. לאור הפסיקה אשר הובאה לעיל, לטעמי התנגדותם של בעלי הדירות, אפילו לא יפגעו הם בעצמם כתוצאה מהבניה, לדוגמא מתוך שיקולי סולידריות עם בעלי דירה אחרים, אינה עולה כדי התנגדות סתמית או כזו אשר נוגדת את עקרונות שיטת המשפט.

88. מסקנה זו מתחדדת על רקע העובדה שלנתבע אין הסכמות אף לא בשיעור הקרוב לרוב הדרוש עפ"י חוק, והוא אף הודה בהגינותו שמקצת בעלי הדירות בבית יפגעו כתוצאה מהבניה. ויטעם, לאור העובדה שהמחוקק קבע כי נדרש רוב מסוים וברור לצורך הרחבת דירה, לא מצאתי לסטות מדרישת רוב זו במקרה דנן ובנסיבות הקיימות.

89. ולבסוף יש לזכור כי על אף קבלתה של התביעה עדיין מתאפשרת הגשמת תכלית ההגנה על החיים, ועדיין מתאפשר לנתבע לבצע מיגון חדר קיים בדירתו, אם כי מבלי לזכות להטבה בדמות תוספת הקומה החלקית שביקש לבנות על הגג המשותף.

סוף דבר-

90. ניתן בזאת צו מניעה קבוע אשר יאסור על הנתבע לבנות על גג הבית המשותף כל עוד לא יהיו בידיו הסכמות של למצער 60% מבעלי הדירות בשני המבנים בבית המשותף.

91. הנתבע ישלם לתובעים, ביחד ולחוד, הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 8,000 ₪. סכום שלא ישולם בתוך 30 יום יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (21.1.14) ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן בהעדר הצדדים ביום א' בטבת התשע"ה (23.12.14).

העתקים יישלחו לצדדים.

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין